

1500445-23.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315660/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 21491108 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2646/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA,

2315660 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500445-23.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-23.2021.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315660/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 21491108 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 2646/21/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA,

2315660 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 19 de novembro de 2021, no período da tarde, na Rua Luiz Carlini, s/n, Jardim Reseck, nesta cidade e Comarca de Artur Nogueira, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 15 porção de Cocaína na forma de Crack, totalizando 1,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, os guardas municipais avistaram LUCAS DOS SANTOS BARBOSA agachado em um canteiro de uma residência em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, o denunciado empreendeu fuga, motivo pelo qual os guardas decidiram

realizar a abordagem e o detiveram logo em seguida. Durante a busca pessoal, foram encontrados em sua cueca 15 pedras de Crack e em uma de suas mãos havia R\$ 172,00 em dinheiro.

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.13-17), pelo auto de exibição e apreensão (fls.18-19), pelos laudos periciais (fls. 123-125) que resultaram positivos para a droga encontrada e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o guarda municipal, ANDRÉ RENZO DE JESUS, na fase policial, disse que estava em Patrulhamento de rotina pelo bairro do Jd Planalto, nesta cidade, e estando pela Rua Luiz Carline, esquina com a Rua Luiz Carlos Tagliari, avistaram dois indivíduos agachados num canteiro de uma casa. Ao avistarem a viatura, um deles saiu correndo pela rua, sendo acompanhado pela viatura. O agente da GCM desceu da viatura e abordou o outro indivíduo no local em que estavam agachados. O rapaz que foi abordado no local foi identificado como sendo o adolescente Gabriel Alves Teixeira e, após ser revistado, com ele foram localizados 8 (oito) eppendorfs contendo substância esbranquiçada aparentando ser cocaína em uma das mãos, e mais 08 (oito) eppendorfs com a mesma substância aparentando ser cocaína no chão onde ele estava agachado, e um aparelho celular de marca Motorola. A testemunha ficou na viatura, e foi no acompanhamento do outro indivíduo que saiu correndo a pé, e logo em seguida, uns 50 metros, conseguiram abordá-lo e identifica-lo como sendo o imputável, Lucas dos Santos Barbosa. Em revista pessoal foi localizado em suas vestes, mais precisamente na sua cueca, 15 (quinze) pedras de crack, bem como estava na posse de um aparelho de celular e uma das mãos havia R\$ 172,00 em dinheiro. O adolescente Gabriel Alves Teixeira ao ser indagado sobre a droga localizada em sua mão e as demais porções que estavam no chão ao seu lado, afirmou que as drogas eram de sua propriedade, alegando ser usuário, negando estar na prática do Tráfico de Drogas. Lucas dos Santos Barbosa ao ser indagado sobre a droga localizada consigo e o dinheiro, disse que apenas é usuário de drogas dizendo que passa na região do "Bar do Osvaldo", apenas para comprar drogas para seu uso. Em juízo manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o guarda municipal, RAPHAEL DOS SANTOS, prestou as declarações dos fatos tal qual o seu parceiro ANDRÉ RENZO DE JESUS .

LUCAS DOS SANTOS BARBOSA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, disse que reside nesta cidade de Artur Nogueira com seus pais e seus irmãos, na rua Johannes Teodoro Wit, n. 516, Jd Paraíso, que atualmente está desempregado, mas já havia entregue os documentos para uma empresa que trabalha com instalação e manutenção de internet iria começar a trabalhar na próxima semana. Afirmou que é usuário de todos os tipos de drogas, maconha, cocaína crack, lança perfume e ingere bebida alcoólica, dizendo que usa em maior quantidade crack e cocaína. Contou que nesta manhã por volta das 10h, foi até o Bar do Zulmiro, para tomar uma cerveja e ali encontrou seu primo qual lhe chamou para ele juntos na lotérica para ele sacar o seguro-desemprego. Que saiu da lotérica e voltou para o bar do foi para o Bar do Osvaldo para ver se havia alguém ali nas proximidades vendendo drogas para o seu consumo, disse que foi até o campo do "rapadão" e ali adquiriu algumas porções de

crack por R\$ 100,00, teria comprado 15 (quinze) pedras de crack. As drogas ficaram consigo na sua mão, e saiu andando pelo bairro, e avistou uma viatura da Guarda Municipal e acabou escondendo as drogas em uma calçada, mas os Guardas viram que estava escondendo, e logo em seguida o abordaram. Alega que havia dispensado as drogas que estavam consigo, as quinze pedras. Ao ser abordado foi localizado um aparelho de celular que lhe pertence e R\$ 172,00 reais em dinheiro, que afirma ser fruto do bico de ajudante de construção. Negou que estivesse na prática do tráfico de drogas, alegando apenas ser usuário. Que ao chegar no Bar do Osvaldo, viu que o adolescente Gabriel estava passando pela rua. Perguntado sobre Gabriel, informa que ele não estava em sua companhia no momento da abordagem. Perguntado, negou que estivesse vendendo drogas. Em juízo manteve sua versão dos fatos. Cabe ressaltar que o réu foi abordado pelos guardas municipais, pois estava, supostamente, agachado em um canteiro.

O entendimento que prevalece no C. STJ, ensinamento que se extrai do RHC 158580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, é que a realização de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige-se, em termos de standard probatório, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

O art. 244 do CPP dispõe que: "A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

Assim, não são autorizadas buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória.

Além disso, a busca pessoal não pode ser realizada com base unicamente em denúncias anônimas ou intuições e impressões subjetivas, pois essas circunstâncias não preenchem o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. Cabe ressaltar que o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Desse modo, se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

Nesse mesmo sentido:

Com efeito, observa-se que a atuação dos guardas municipais não se baseou em nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, mas tão somente em uma alegada "atitude suspeita" das pacientes. No caso, os agentes públicos somente encontraram os entorpecentes após realização de busca pessoal, o que constitui verdadeira atividade de investigação que extrapola as competências previstas para as guardas civis municipais, quais sejam, proteção dos bens, serviços e instalações do município (art. 144, § 8º, CF). [...] (HC n. 736.926/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decisão monocrática, DJe 26/4/2022, grifei).

A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade.

Portanto, não há controvérsia quanto à possibilidade de a guarda municipal realizar a prisão de agente em delito flagrante, ou quando haja indícios sérios. Ocorre que a prisão, no caso dos autos, aconteceu depois de abordagem irregular, pois destituída de fundada suspeita.

No mais, os contornos mínimos de eventual crime só foram constatados depois da abordagem, sem perseguição ou indícios prévios do delito, configurando-se atuação irregular. Isso porque mero nervosismo diante da aproximação de terceiros não é elemento indiciário suficiente do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem de pessoa por outra "qualquer do povo",

condição à qual equivale o agente público que não se inclui entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144, caput, da CF/88.

No caso dos presentes autos, os entorpecentes só foram localizados depois da revista pessoal por funcionário público que não é policial, o que evidencia a irregularidade por ausência de causa justa e prévia.

Restando, portanto, configurada a ilegalidade da abordagem da guarda municipal fundada em atitude suspeita pelo simples fato do réu encontrar-se agachado.

Diante das provas angariadas sob o crivo do contraditório, não há nos autos elementos mínimos de que a droga apreendida com o acusado se destinava ao comércio. Não obstante a quantidade apreendida, não se mostra possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as drogas encontradas se destinassem ao tráfico.

Ainda, réu manteve coerência e linearidade na versão que apresentou em Juízo, assim, não há como reconhecer a traficância, pois, não há elementos aptos a desmentirem a versão apresentada pelo réu ocasião em que ouvido.

O denunciado confessou o uso de entorpecente, nada de ilícito foi localizado no celular, bem como não há outros indícios de traficância.

No mais, em delegacia, o próprio adolescente, não ouvido nessa ocasião, assim o réu, afirmaram que não estavam próximos e que não foram abordados em conjunto pela guarda civil.

Neste panorama, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 se impõe como medida mais sensata, aplicando-se o princípio "in dubio pro reo". Aliás:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES LEI N.º 11.343/06, ART. 33, CAPUT.

DESCCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE, PREVISTO NO ART. 28. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. Comprovada apenas a apreensão de pequena quantidade de droga, desclassifica a conduta para posse de entorpecente, prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. (TJ-SP, Apelação n. 0001568-68.2010.8.26.0077, 13ª Câmara de Direito Criminal Relator: Renê Ricupero, Data de Julgamento: 15/09/2011).

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, LUCAS trazia consigo, para consumo pessoal, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na exata correspondência com a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Inexistem, por fim, causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a sua punibilidade, reconheço a ocorrência do delito e passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na determinação da pena há previsão legal de três sanções: advertência, prestação de serviços à comunidade (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses).

Aplico a penalidade de advertência, medida suficiente para prevenção, reprovação e reeducação do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu LUCAS DOS SANTOS BARBOSA a pena de advertência por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

O réu poderá recorrer em liberdade, pois não se vislumbram motivos ensejadores da prisão preventiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Registre-se e façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Artur Nogueira, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA